

1501649-32.2021.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Patrícia Helena Hehl Forjaz de Toledo

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/01/2022

... a responsabilidade do apelante pelo crime de tráfico de drogas. 2.

Inaplicabilidade da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06. A prática de ato infracional equivalente ao tráfico de drogas pode ser considerada como dado a obstar a aplicação da minorante prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06. Precedentes do STJ. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

2ª Vara Criminal

Avenida Sete de Setembro, 399, Diadema-SP - cep 09912-010

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501649-32.2021.8.26.0537 - Controle nº 2021/001188

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2225213/2021 - 03º D.P. DIADEMA, 19709486 - 03º D.P.

DIADEMA, 2225213 - 03º D.P. DIADEMA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Rafael Rodrigo Pereira Barbosa

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Patrícia Helena Hehl Forjaz de Toledo

Vistos.

RAFAEL RODRIGO PEREIRA BARBOSA, qualificada às fls. 10/12, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, porque no dia 18 de agosto de 2021, por volta das 16h10, na Rua Serra Uassari, altura do nº 141, Campanário, nesta cidade de Diadema, trazia com ele e guardava, para fins de entrega a consumo de terceiros, 128 embalagens plásticas contendo 78g da droga cocaína, 181 embalagens plásticas contendo 73g da mesma droga, na forma de crack, e 124 embalagens plásticas contendo 237g da droga maconha, conforme auto de apreensão e exibição de fls. 19/20 e laudo de constatação provisória de fls. 16/18, agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Convertida a prisão em flagrante em preventiva (fls.53/56), foi-lhe nomeado

Defensor Público, quem apresentou defesa inicial às fls.100/102. Não sendo hipótese de arquivamento, a denúncia foi recebida em 17/11/21 (fl.104) e certificadas a notificação e a citação positivas do Réu as fl.95 e 133.

Em audiência de instrução, debates e julgamento foram ouvidas as testemunhas comuns e interrogado o réu ao final. Encerrada a instrução sem requerimento de diligências, seguiu-se com os debates orais (tudo em mídia digital).

Nestes, o Órgão Ministerial requereu a procedência da ação por provadas autorias e materialidade delitivas. Pleiteou a fixação da pena base bem acima do mínimo diante da quantidade e nocividade da droga cocaína, concordando com as atenuantes da menoridade relativa e da confissão, com a redução da pena em percentual mínimo, mas não também por sua substituição pela pena restritiva de direitos, fixando-se regime prisional fechado, mais a perda do numerário apreendido.

Já o d. Defensor Público reiterou o pedido de absolvição ante a fragilidade probatória. Subsidiariamente, requereu que a pena-base fosse fixada no mínimo legal, com as duas atenuantes já referidas, e o redutor da pena em percentual maior, além de sua substituição com fulcro no art. 44 do CP, fixando-se regime aberto e possibilidade de recurso em liberdade, até pela detração penal.

É o breve relatório.

Passo a fundamentar e decidir.

A ação procede.

A materialidade delitiva vem estampada no auto de exibição e apreensão de fls.19/20, nos laudos de constatação e no definitivo (fls.16/18 e 88/90), ambos positivos para as drogas maconha e cocaína.

A autoria é inconteste não só com fulcro na prova amealhada extrajudicialmente, como na colhida sob o manto do contraditório que corrobora àquela e a qual passo a expor.

Segundo narrativas administrativas dos policiais militares (fl. 08 e 09) realizavam de rotina pelo bairro Campanário, em local conhecido como ponto de tráfico (Rua Serra do Uassari, altura do n. 414) quando avistaram um indivíduo segurando uma sacola plástica e com aparente nervosismo ao perceber a presença policial, o que motivou a abordagem. Ao supor que seria abordado, o indivíduo dispensou a sacola e empreendeu fuga, sendo contido a aproximadamente 20 metros adiante. Na busca pessoal nada encontraram de ilícito. Contudo, na sacola dispensada pelo indivíduo localizaram: 124 invólucros plásticos com substância esverdeada aparentando ser maconha, 128 invólucros com substância branca aparentando ser cocaína e 181 papелotes com material aparentando ser crack, todos embalados e individualizados para o comércio ilícito. Também foi apreendido com o conduzido, em seu bolso, o montante de R\$94,00.

Sob o crivo do contraditório os policiais Paulo Correa Jr. e Thiago Ré reiteraram que estavam em patrulhamento pelo local já conhecido como ponto de tráfico de entorpecentes. O réu foi visto com uma sacola na mão. Ao notar suas presenças, demonstrou nervosismo e passou a andar. Ao notar que ia ser abordado, largou a sacola ao solo e tentou correr, mas foi alcançado e detido. Ele disse que estava lá para levar as drogas para uma menina distribuir na biqueira. Eram os três tipos de drogas mais comuns, já separados individualmente, em grande quantidade, e uma quantia em dinheiro. Reconhecem o acusado.

O réu, em solo policial (fl.10) sustentou que estava no local da abordagem, mas as drogas estavam em posse de uma terceira pessoa, de nome Talita, sendo que não tem qualquer relação com a droga. Detalhou que passa por problemas financeiros e iria

iniciar no tráfico mediante o recebimento da quantia de R\$1.000,00 semanais, contudo sequer chegou a começar a traficância.

Em juízo o acusado alegou que estava passando necessidades e teve proposta para levar as drogas num local e entregar para uma pessoa. Ao chegar lá deu de frente com os policiais e tentou correr. Está arrependido. Já teve passagem pela Vara da Infância e Juventude, com duas internações, por tráfico e roubo.

Logo, o interrogatório com a confissão do acusado, que não é prova única, pois veio corroborada pelos depoimentos dos testemunhos - que são válidos e eficazes para a convicção condenatória, até por não haver dúvidas sobre sua lisura - estão em consonância com os demais elementos probatórios contidos nos autos, sendo corroborados pelo auto de apreensão e exibição, além das provas periciais, sem prova contrária, até porque o réu admitiu que aceitou traficar por estar passando por dificuldades financeiras e ter uma filha para sustentar e esposa.

Ademais, é cediço que no crime de tráfico de drogas, em regra, a prova é baseada nos depoimentos dos policiais. A defesa não apresentou nenhuma prova concreta capaz de ilidir as declarações dos policiais militares, não havendo motivo plausível para seu desmerecimento, consoante Enunciado 70 da Súmula de Jurisprudência do STJ.

Ainda que não presenciado qualquer ato de comércio, as circunstâncias do flagrante demonstram a conduta prevista no art. 33, caput, da Lei de Drogas, que consigna como verbos nucleares trazer consigo e guardar, condutas perpetradas pelo réu, comprovada a circulabilidade. O tráfico de drogas é crime de ação múltipla e a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, é suficiente para a consumação da infração, sendo prescindível a realização de atos de venda do entorpecente.

Afasto tese de estado de necessidade ou dificuldade financeira, pois os bens jurídicos são desproporcionais, por se colocar em risco a saúde pública, de interesse da sociedade, em detrimento do interesse individual, além de se tratar de crime de perigo abstrato. Ainda: Não há que se falar em estado de necessidade, pois não há provas nos autos de que o apelante passava por miserabilidade extrema a ponto de ter que violar a lei para sobreviver. A mera dificuldade financeira não autoriza ninguém a praticar delitos' (TJSP, Apelação Criminal n.º 0006727-87.2004.8.26.0081, Rel. Caio Ferraz de Camargo Lopasso, 5.ª Câmara Criminal D.J.E., j. em 29.07.2011).

À luz do art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06, a natureza e grande quantidade de drogas (cocaína e crack principalmente), o local da prisão (um ponto de venda de drogas conhecido), o numerário apreendido (fl.65), são fatores que, reunidos, permitem a conclusão indubitável de que o elemento subjetivo do agente dirigia-se especificamente à mercancia e não ao mero consumo pessoal, de modo que a procedência do pedido é inarredável.

Passa-se, pois, à dosimetria da pena.

Observado o art. 59 do Código Penal, os motivos, circunstâncias e consequências do delito, e especialmente pela excessiva quantidade do narcótico apreendido (433 no total), às vistas do disposto no art. 42 da Lei de Drogas, fixo em primeira fase, a pena base acima do mínimo legal, ou seja, em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Em segunda fase, não há circunstâncias agravantes e sim as atenuantes da menoridade relativa (fl.12) e da confissão espontânea, e tendo sido utilizado o interrogatório como meio de prova de autoria para a fundamentação do presente decreto condenatório, milita em seu favor a atenuante genérica prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, a reduzir a pena ao mínimo legal: 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Em terceira etapa, não concorrem causas de aumento de pena. Quanto ao privilégio previsto no §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, sendo o acusado primário (fls.72/74), mas com passagem pela Vara da Infância e Juventude, interação inclusive por crime análogo, somado ao numerário apreendido, indicativo de que vendas foram efetivamente feitas a usuários, propiciando assim o vício entre eles, demonstrando maior dedicação à traficância, tudo somado à qualidade da droga, o alto poder lesivo da cocaína e do crack, opto pelo redutor de 1/6 totalizando 04 anos e 02 meses de reclusão e 416 dias-multa, cada qual fixado em 1/30 do valor do salário mínimo atual tendo em conta ausência de elementos nos autos indicativos da capacidade financeira do Condenado.

Quanto ao percentual acima fixado, justifico, ainda, através da jurisprudência que cito: 1. Conjunto probatório a evidenciar a responsabilidade do apelante pelo crime de tráfico de drogas. 2. Inaplicabilidade da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06. A prática de ato infracional equivalente ao tráfico de drogas pode ser considerada como dado a obstar a aplicação da minorante prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06. Precedentes do STJ. 3. Sanção que não comporta reparo. Recurso improvido." (TJSP; Apelação Criminal 1500078-39.2018.8.26.0599; Relator (a): Laerte Marrone; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Piracicaba - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 27/06/2019; Data de Registro: 01/07/2019) – grifos nossos. A teor do disposto nos artigos 33, do Código Penal, o regime prisional semiaberto é o que se impõe, considerando a quantidade da pena que no caso em tela não comporta regime mais brando como pretende a Defesa, mas especialmente pela preponderância da natureza e da quantidade da droga, não ficando o juiz obrigado a fixar regime inicial relacionado unicamente com o quantum da pena, podendo optar por um mais gravoso ao observar a regra do artigo 33, parágrafo 2º, do Código Penal, em conjunto com o artigo 42 da Lei 11.343/2006. Veja: Conforme entendimento jurisprudencial consolidado nesta Corte, não constitui bis in idem a utilização do fundamento com base na quantidade expressiva de droga apreendida para elevar a pena-base e, também, para estabelecer o regime prisional. (AgInt no REsp 1.539.980/PR, j. 11/04/2019). E regime fechado ao réu primário, relativamente menor e confesso, seria um excesso.

Incabível a benesse do art. 44 do CP, não se mostrando suficiente nem eficaz à reprovação da conduta do agente, menos ainda socialmente recomendável sob pena de potencializar a sensação de insegurança e intranquilidade social, a merecer maior reprovabilidade a conduta, dado que viola mais intensamente o bem jurídico tutelado, somado ao elevado número de ocorrências de tal natureza conferindo constante desassossego à sociedade, a exigir firme repressão do Estado como forma de desestimular o crime, geralmente cometido graças ao nível de organização próprio daqueles que fazem do tráfico seu meio de vida.

Some-se a isso o fato de que: O artigo 44, caput, da Lei de Drogas veda, expressamente, a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos para o condenado pelos crimes previstos nos artigos 33, caput e parágrafo 1º, e 34 a 37. Já o artigo 33, parágrafo 4º, da Lei de Drogas, que prevê uma causa de diminuição de pena, também estabelece, no caso de sua aplicação, que a pena privativa de liberdade não poderá ser substituída por restritiva de direitos. Ainda, a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de não ser possível a aludida substituição para o condenado por tráfico de drogas e condutas correlatas (artigos 33, caput e parágrafo 10, e 34 a 37), bem como quando da aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei de Drogas (HC 144.915/MG, Rel. Laurita Vaz, v.u., j. 01.06.2010. No mesmo sentido – STJ – HC 136.618/MG, 5ª t., Rel. Min. Laurita Vaz, v.u., j. 01.06.2010). ... Ora, não nos parece razoável proceder a substituição para autor de crime de suma gravidade. A personalidade, a conduta social e culpabilidade do traficante de drogas e de quem de qualquer forma o auxilia, bem como as consequências do crime, que são nefastas para o viciado e usuário e para a

sociedade, não recomendam a substituição, que pode ser indeferida nos termos do artigo 44, III, do Código Penal. Ressalte-se, por fim, que a droga é o câncer que assola a todo o mundo já que, direta ou indiretamente, é responsável por boa parte dos crimes violentos que o afligem. Por causa dela as pessoas matam ou são mortas. É muito difícil um crime violento não ter a droga como estopim. Ou o agente está sob seu efeito, ou é vítima de um traficante ou de um drogado, ou é um traficante que mata um rival etc. Enfim, a droga, de uma maneira ou de outra, está ligada aos crimes mais graves.

Custodiado no curso do processo, o Condenado não poderá exercer o direito de recorrer em liberdade, com mais razão ante a pena aplicada após exauriente cognição e diante do necessário resguardo da ordem pública e da aplicação da lei penal, verificada a possibilidade concreta da continuidade de práticas delitivas por já ter passagens pela Vara da Infância e Juventude, bem como constatada ausência de vínculos firmes no distrito da culpa, sendo incongruente soltá-lo, inclusive para a segurança pública e para a conveniência da aplicação da lei penal. (...) Não há lógica em permitir que o réu, preso (...) durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar (...) (STF HC nº 89.824/MS Rel. Ministro Ayres Britto Dje. 28.08.2008; STJ RHC nº 111.421/RJ, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, j. 03.10.2019, DJe 10.10.2019; RHC nº 118.468/MG, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17.10.2019, DJe 25.10.2019; RHC nº 34.998/RJ Rel. Ministro Jorge Mussi Dje 20.03.2013).

Reconheço a custódia cautelar do Condenado desde a data do fato, sem reconhecer-lhe direito à detração penal ou à progressão de regime, tendo em vista os critérios legais objetivos e a falta de atestado de bom comportamento carcerário atualizado. Assim, deixo de me manifestar sobre a detração penal, parecendo mais adequado que o juízo da execução se manifeste por primeiro, observando-se também os princípios constitucionais do duplo grau de jurisdição, da individualização da pena e do juiz natural. Não bastasse isso, progressão de regime é matéria a ser apreciada pelo juiz da execução, competente para tanto, nos moldes do art. 112 da LEP, caso contrário, o preso provisório obteria um benefício sem se verificar, primeiramente, se preenche os requisitos da referida Lei especial, que prevalece sobre a geral. Neste sentido, posicionamento do E. Superior Tribunal de Justiça: A previsão inserida no § 2.º do art. 387 do Código de Processo Penal, não se refere à verificação dos requisitos para a progressão de regime, instituto que se restringe à execução penal, mas da possibilidade de o Juízo de 1.º Grau, no momento oportuno da prolação da sentença, estabelecer regime inicial mais brando, em razão da detração. Ainda que realizado o desconto do quantum da pena, do período em que o réu se manteve em custódia preventiva, não há óbice de que o magistrado fixe regime inicial mais gravoso, fundamentando-se nas circunstâncias do caso concreto, que recomendam maior rigor no cumprimento da pena (STJ, 5.ª Turma, HC n.º 361092/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 05/11/2015, grifei). Raciocinar em sentido contrário seria admitir uma espécie de “progressão de regime” pelo juízo criminal (que não tem competência para tanto), sem a análise dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos pela Lei de Execuções Penais.

Por fim, não há valor mínimo de reparação do dano a ser arbitrado.

DISPOSITIVO.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO contra RAFAEL RODRIGO PEREIRA BARBOSA, qualificado às fls. 10/12, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e o faço para condená-lo à pena de 04 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais ao pagamento de 416 dias-multa, cada qual fixado em 1/30 do valor do salário mínimo a época dos fatos.

O condenado não poderá apelar em liberdade. Recomendando-o no cárcere compatível com o

regime ora fixado.

Sendo ele assistido pela DPE, reconheço suspensa a exigibilidade de custas e despesas processuais, por ora.

Decreto a perda de valores apreendidos nestes autos (fl. 65), com fulcro no art. 63 da Lei 11.343/06. E determino a destruição de todas as drogas.

Com o trânsito em julgado desta sentença, opere-se a detração penal, certifique-se e extraia-se a guia de recolhimento definitiva em relação à pena corporal, encaminhando-se à V.E.C. competente, certifique-se o cálculo da pena de multa, intime-se o réu a paga-la em 10 dias sob pena de extração de certidões da Sentença para a Procuradoria Geral do Estado (dívida ativa. Oficie-se ao Senad, ao IIRGD e TRE.

Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados. Cumpra-se.

Diadema, 27 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA